

<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

<제10장 부작위위법확인소송 및 기타소송.제01절 부작위위법확인소송>

[기출][2011-1]면적축소 관련 법령에 대한 취소소송 및 환원처분을 구하는 소송의 적법성 여부

《【문제1】 관할 행정청은甲의 어업면허의 유효기간이 만료됨에 따라 동 어업면허의 연장을 허가하여 새로이 어업면허를 함에 있어서 관련법령에 따라 면허면적을 종전의 어업면허보다 축소하였다.甲이 자신의 재산권을 침해하는 면허면적축소와 관련된 법령의 취소를 청구하는 행정소송을 제기하거나, 어업면허면적을 종전으로 환원하여 주는 처분을 청구하는 행정소송을 제기하는 것이 적법하게 인정될 수 있는가? (50점)》

<문제1> 면적축소 관련 법령에 대한 취소소송 및 환원처분을 구하는 소송의 적법성 여부

I. 문제 제기

-사안에서 관할 행정청은甲의 어업면허 갱신 시 관련 법령에 따라 종전보다 축소된 면적으로 어업면허를 하였고, 이에甲은 면허면적 축소의 근거가 된 법령의 취소 또는 종전 면적으로의 환원을 구하는 행정소송을 제기하고자 한다. 쟁점으로 <법령의 취소를 구하는 행정소송과 종전 면적으로의 환원을 구하는 행정소송이 현행 행정소송법상 허용되는지> 여부를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 면허면적축소와 관련된 법령의 취소를 청구하는 행정소송 또는 어업면허면적을 종전으로 환원하여 주는 처분을 청구하는 행정소송이 적법하게 인정될 수 있는가를 설명한다.

II. 면허면적축소와 관련된 법령의 취소를 청구하는 행정소송의 적법성

1. 취소소송의 대상 (처분등)

(1) 행정행위의 처분성

-“행정소송법 제19조”는 취소소송은 처분등을 대상으로 한다고 규정하며, “행정소송법 제2조 제1항 제1호”에서는 처분등을 행정청이 행하는 구체적인 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용으로 규정한다.

(2) 법규명령의 처분성

① 원칙

-법규명령(법령)은 일반적·추상적 규율로서 직접적으로 국민의 권리·의무에 변동을 초래하는 것이 아니므로, 원칙적으로 행정소송의 대상인 처분등에 해당하지 않는다. 법규명령은 그 자체로서는 행정소송의 대상이 되지 않고, 그 법규명령에 근거하여 행정청이 한 구체적인 처분이 비로소 소송의 대상이 된다.

② 예외 (집행행위 없이 직접 국민의 권리·의무를 규율하는 경우)

-일부 법규명령은 그 내용이 개별적이고 구체적이어서, 별도의 집행행위를 기다릴 필요 없이 그 자체로 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미치는 경우가 있다. 이러한 법규명령은 예외적으로 처분성을 인정하여 항고소송의 대상이 될 수 있다는 것이 “판례”의 입장이다. (예 : 구 병역법시행령 조항의 특정 조항, 또는 고시·계획 등의 처분성 인정 등).

2. 법령에 대한 위헌·위법 심사 방식

-법령 자체에 위헌·위법이 있다고 주장하는 경우, 직접 법령의 취소를 구하는 소송이 아니라 다음과 같은 방법으로 다투어야 한다.

(1) 구체적 규범 통제

-해당 법령에 근거한 구체적인 처분(어업면허처분)에 대한 취소소송을 제기하면서, 그 소송에서 선결문제로서 해당 법령의 위헌·위법 여부를 다투는 방식이다. 법원은 처분의 위법성 판단을 위해 법령의 위헌·위법 여부를 심사할 수 있고, 법령이 위헌·위법하다고 판단되면 그 법령에 근거한 처분을 취소할 수 있다. 이것이 간접적으로 법령의 효력을 부인하는 방법이다.

(2) 헌법소원

-법령 자체로 인해 직접적으로 기본권이 침해되는 경우, 헌법재판소에 헌법소원(“헌법재판소법 제68조 제1항”)을 청구할 수 있다. 다만, 이 경우에도 원칙적으로 법령 자체에 대한 공권력 행사성이 인정되어야 하고, 다른 법률에 구제절차가 없는 경우에만 보충적으로 허용된다.

3. 사안의 적용

-甲이 취소를 청구하는 대상은 면허면적축소와 관련된 법령이다. 어업면허면적을 축소하도록 규정한 관련 법령은 일반적·추상적인 규범으로서, 그 자체로甲의 어업면허면적을 축소시키는 것이 아니라, 그 법령에 근거하여 이루어진 어업면허(갱신) 처분이甲의 면허면적을 축소시키는 직접적인 행위이다. 따라서 이 법령은 별도의 집행행위(어업면허처분)를 매개로 하여甲의 권리·의무에 영향을 미치므로, 그 자체로 처분성을 가진다고 보기 어렵다. 법령 자체에 대한 취소소송은 대상적격을 갖추지 못한다.

4. 검토

-甲이 면허면적축소와 관련된 법령의 취소를 직접 청구하는 행정소송은 적법하게 인정될 수 없다. 해당 법령은 그 자체로甲의 권리·의무에 직접적인 변동을 초래하는 처분에 해당하지 않으므로, 취소소송의 대상적격을 결여하기 때문이다.甲은 해당 법령에 근거한 어업면허 처분(면허면적축소가 포함된 처분)에 대한 취소소송을 제기하면서, 그 소송에서 법령의 위법성을 다투는 구체적 규범 통제 방식을 취해야 한다.

III. 어업면허면적을 종전으로 환원하여 주는 처분을 청구하는 행정소송의 적법성

1. 소의 종류 선택(취소소송인가, 의무이행소송인가?)

(1) 어업면허의 연장(갱신)과 법적 성격

-어업면허는 특정인에게 독점적으로 어업권을 부여하는 특허에 해당한다. 어업면허의 연장(갱신)은 기존 면허의 유효기간 만료와 함께 새로운 면허를 부여하는 것으로 해석하는 것이 “판례”의 일반적인 태도이다. 이는 기존 면허의 효력을 그대로 연장하는 것이 아니라, 새로운 면허 부여의 재량행위로 본다. 따라서 재량권이 행사될 여지가 있다.

(2) 면허면적축소의 법적 성격

-어업면허의 축소는 종전의 어업면허에 비해 불이익을 주는 처분이므로 수익적 행정행위의 변경(불이익 변경) 또는 재량권 행사의 문제로 볼 수 있다. 사안은 면허연장 과정에서 면허면적을 축소한 경우이므로, 기존의 어업면허가 만료되고 축소된 면적으로 새로운 어업면허를 발급한 재량행위에 해당한다.

(3)甲의 청구의 의미

-甲은 어업면허면적을 종전으로 환원하여 주는 처분을 청구하고 있다. 이는 특정 내용의 적극적 처분(종전 면적으로의 연장 또는 새로운 면허)을 해달라는 요구에 해당한다.

(4) 취소소송의 한계

- 취소소송은 위법한 처분을 취소하는 소극적인 성격을 가진다. 즉, 면허면적축소가 포함된 어업면허 처분이 위법하다고 판단되어 취소된다 하더라도, 법원이 직접 종전 면적으로 환원하는 새로운 어업면허 처분을 하도록 명할 수는 없다. 취소판결은 행정청에게 판결의 취지에 따른 재처분 의무를 발생시키지만, 그 재처분의 내용이 반드시 甲이 원하는 종전 면적 환원이 되어야 하는 것은 아니다(행정청이 재량권을 다시 행사할 수 있다).

(5) 의무이행소송의 필요성 (현행법상 부인)

- 甲이 원하는 것은 특정 내용의 처분(종전 면적으로의 환원)을 해달라는 것이므로, 이는 법원이 행정청에게 특정 처분을 명해줄 것을 구하는 의무이행소송의 성격을 가진다. 그러나 우리 행정소송법은 의무이행소송을 명시적으로 인정하고 있지 않다. 현행법 해석상 거부처분에 대한 취소소송이 인용되어도 행정청은 판결의 기속력에 따라 재처분 의무를 지지만, 다른 사유로 다시 거부처분을 할 수 있다. 결국 취소소송만으로는 甲의 목적 달성이 어렵다. 그러나 의무이행소송은 우리 행정소송법이 예정하고 있지 않으므로, 이러한 소송을 제기하더라도 법원은 각하할 것이다.

2. 현행법상 적법하게 인정될 수 있는 소송의 형태

(1) 어업면허(연장 또는 갱신) 처분에 대한 취소소송

- 甲의 재산권을 침해하는 면허면적축소가 포함된 새로운 어업면허 처분 자체가 위법하다고 판단될 경우, 그 처분 전체 또는 면적 축소 부분에 대한 취소소송을 제기할 수 있다. 이 경우 법원은 해당 처분이 재량권의 일탈·남용으로 위법한지 여부를 심리하게 된다. 만약 위법하다면 취소판결을 내릴 것이고, 행정청은 기속력에 따라 재처분을 해야 한다. 그러나 재처분의 내용이 반드시 종전 면적으로의 환원이 될 것이라고 단정하기 어렵다. 만약 법령 자체의 위법성이 선결문제로 인정되어 처분이 위법하다고 판단된다면, 그 법령에 근거한 처분(면적 축소 포함)을 취소할 수 있다.

(2) 거부처분 취소소송 (간접적 구제)

- 만약 甲이 면적 축소에 대해 별도로 이의를 제기하며 종전 면적으로 연장해 달라는 신청을 했고, 행정청이 이를 거부하는 처분을 했다면, 甲은 그 거부처분에 대한 취소소송을 제기할 수 있다. 이 경우 법원이 거부처분을 취소하면 행정청은 다시 신청에 대해 처분을 해야 할 의무를 지지만, 역시 반드시 종전 면적으로 환원하는 처분을 해야 하는 것은 아니다.

3. 사안의 적용

- 甲이 원하는 종전 면적으로의 환원 처분을 직접적으로 명하는 소송은 의무이행소송에 해당하며, 이는 현행법상 인정되지 않아 부적법하다. 따라서 甲이 취할 수 있는 유일하고 적법한 소송 형태는 행정청이 발급한 축소 면허 처분 전체를 대상으로 하는 취소소송이며, 이 소송의 승소 판결을 통해 재처분 의무를 발생시켜 간접적인 구제를 받아야 한다.

4. 검토

- 甲이 어업면허면적을 종전으로 환원하여 주는 처분을 직접 청구하는 형태의 행정소송은, 우리 행정소송법이 특정 처분을 명하는 의무이행소송을 인정하고 있지 않으므로, 적법하게 인정될 수 없다. 따라서 甲은 다음과 같은 방법을 취하여 간접적인 구제를 시도해야 한다. ❶ 새로이 발급된 어업면허(축소된 면적의) 처분에 대해 그 면적 축소 부분이 재량권 일탈·남용 등으로 위법하다고 주장하며 취소소송을 제기하여 승소한 후, 행정청이 재량권을 다시 행사하도록 유도하는 방법. ❷ 만약 종전 면적으로의 환원을 별도로 신청하였으나 행정청이 이를 거부하는 처분을 했다면, 그 거부처분에 대한 취소소송을 제기하는 방법. 이 두 가지 경우 모두 법원이 직접 행정청에게 종전 면적으로 환원하는 처분을 하라고 명할 수는 없다.

Ⅳ. 종합 결론

- 甲이 제기하고자 하는 두 가지 유형의 행정소송의 적법성에 대한 결론은 다음과 같다. ❶ 면허면적축소와 관련된 법령의 취소를 청구하는 행정소송은 법규명령으로서 취소소송의 대상인 처분에 해당하지 않아 대상적격이 없으므로 적법하게 인정될 수 없다. ❷ 어업면허면적을 종전으로 환원하여 주는 처분을 청구하는 행정소송은 현행 행정소송법상 인정되지 않는 의무이행소송의 형태이므로 적법하게 인정될 수 없다. 따라서 甲은 현행법상 축소된 어업면허 처분 전체를 대상으로 하는 취소소송을 제기하고, 그 소송에서 법령의 위법성을 다투어 승소함으로써, 행정청의 재처분을 통해 종전 면적으로의 면허를 간접적으로 확보하는 것이 유일하고 적법한 구제 경로이다.